Processo nº 0094391-41.2022.8.17.2001

AUTOR(A): MARIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA ALMEIDA

RÉU: CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

SENTENÇA

MARIANA FAUSTINO DE OLIVEIRA ALMEIDA, já qualificada, por intermédio de advogados constituídos, promoveu a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS, também qualificado, através da qual buscou-se compelir a demandada a autorizar a realização de cirurgia reparadora, uma vez que teria perdido mais de 30kg e havia a necessidade de resolver o problema estético e psicológico ao qual sofria, diante da queda de pele decorrente da perda de peso, tudo em conformidade com os laudos médicos anexados aos autos.

Narrou na exordial que foi diagnosticada com obesidade mórbida, sendo indicação médica para o tratamento a realização de cirurgia bariátrica, a qual a autora submeteu-se, evoluindo com perda maciça de peso de aproximadamente 30 (trinta) quilos.

Em decorrência da bem-sucedida cirurgia bariátrica realizada, como dito acima, a Requerente emagreceu aproximadamente 30 kg, perdendo uma notável quantidade de massa corporal, acarretando nesses casos, desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica, além da dermatite do sulco inflamatório.

Prossegue narrando que o seu médico assistente solicitou a realização do procedimento cirúrgico para a higiene do sulco inflamatório, em razão da acentuada ptose mamaria, qualificando-se como cirurgia reparadora (CID 10: N62 – Hipertrofia mamária). Argumentou que ao pleitear a autorização pelo plano demandado, com notificação prévia, houve uma negativa tácita por parte da ré.

Diante disto, requereu, a concessão da tutela de urgência, para compelir a empresa ré a custear e autorizar o procedimento cirúrgic requestado, com o material necessário a realização da cirurgia. No mérito, a confirmação da tutela, além da condenação da ré numa indenização por danos morais, afora as condenações de estilo em custas e honorários advocatícios. Procedeu com o pagamento das custas processuais (ID. 113707958) e anexou aos autos farta documentação.

Indeferida a tutela pleiteada no ID. 114723464, ante a ausência de perigo de dano, foi determinada a citação/intimação da parte demandada. Houve a interposição de Agravo de Instrumento, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando o custeio dos procedimentos requeridos (ID. 120763050).

Citada/intimada, a demandada apresentou contestação (ID. 115003427), sustentando que a negativa se deu porque os custos alusivos a estes são de caráter estritamente particular e, especificamente, nesse caso, de caráter estético, estando lastreada na legalidade e em sintonia com as normas da ANS, já que a autora não apresentou comorbidades funcionais. Levantou a questão da coparticipação argumentando. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Por sua vez, a autora apresentou réplica, por meio da petição de ID. 118392782.

Não havendo interesse das partes na produção de novas provas, houve a suspensão do feito, ante o Tema nº 1069, que afetou os processos que envolviam a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Julgado o Tema, houve o levantamento da suspensão do feito e os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Passo a decidir.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Verifica-se, inicialmente, que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide, pois não há necessidade de produção de prova em audiência, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, entendo-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto a seu mérito, nos moldes do art.355, I, do CPC/2015.

Dito isto, passo à análise do mérito propriamente dito.

De proêmio, consigne-se que, de fato, a relação entre as partes não se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ante o entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao qual aderiu esta magistrada, firmado

na súmula 608, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do consumidor aos contatos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia sensivelmente essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diversamente dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro.

Ademais, assim como ocorre nos casos de entidades de previdência privada fechada, os valores alocados ao fundo comum obtidos nas entidades de autogestão pertencem aos participantes e beneficiários do plano, existindo explícito mecanismo de solidariedade, de modo que todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus próprios integrantes.

Portanto, as regras do Código Consumerista, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial, não se aplicam às relações envolvendo entidades de planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão.

Assim, o "tratamento legal a ser dado na relação jurídica entre os associados e os planos de saúde de autogestão, os chamados planos fechados, não pode ser o mesmo dos planos comuns, sob pena de se criar prejuízos e desequilíbrios que, se não inviabilizarem a instituição, acabarão elevando o ônus dos demais associados, desrespeitando normas e regulamentos que eles próprios criaram para que o plano se viabilize. Aqueles que seguem e respeitam as normas do plano arcarão com o prejuízo, pois a fonte de receita é a contribuição dos associados acrescida da patronal ou da instituidora" (REsp 1.121.067-PR, Terceira Turma, DJe 3/2/2012). REsp 1.285.483-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/6/2016, DJe 16/8/2016).

Contudo, a não incidência do CDC, por si só, de maneira alguma concede à seguradora justificativa para obstar o acesso do segurado à saúde, quando comprovada tecnicamente a necessidade de submissão a determinado tratamento.

Dito isso, verifico que houve a retirada da suspensão do feito, uma vez que ocorreu o julgamento do Tema nº 1069 (definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica), pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), publicado no dia 19/09/2023.

A discussão na presente lide versa a respeito da legalidade da negativa de autorização das cirurgias indicadas no laudo médico, procedimentos necessários e tidos como continuidade do tratamento de obesidade.

A presente matéria a respeito da obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, levou o STJ à afetação da questão sob o tema repetitivo nº. 1.069, estabelecendo como questão a qual foi submetida a julgamento a “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”.

Ao analisar o Tema 1.069, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou, por unanimidade, duas teses sobre a obrigatoriedade de custeio, pelos planos de saúde, de operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica. Que foram as seguintes:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Vale mencionar que em seu voto o relator Ministro Ricardo Lillas Bôas Cueva, observou que, conforme o artigo 10, *caput*, da Lei 9.656/1998 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm#art10), o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória nos planos de saúde.

O ministro destacou que as operadoras devem custear as cirurgias plásticas pós-bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele, uma vez que, em algumas situações, a plástica não se limita a rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do corpo humano ou, ainda, a prevenir males de saúde.

Villas Bôas Cueva lembrou que o STJ possui jurisprudência no sentido de que a operadora deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências. Ressaltou que, embora a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tenha incluído apenas a dermolipectomia abdominal (substituída pela abdominoplastia) e a diástase dos retos abdominais no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim haver a integralidade de ações na recuperação do paciente.

Dessa maneira, analisando os autos, resta evidente e incontroverso o fato de a autora ter feito cirurgia bariátrica, fato confessado pela ré, eficaz para o tratamento de obesidade, gerou grande perda de peso e em consequência, flacidez de mamas, abdômen e demais partes do corpo, conforme atestado pelo laudo médico anexado aos autos.

O laudo médico apresentado pela autora deixa claro que tais procedimentos são necessários e não há dúvida que tudo isso é continuidade do tratamento para a obesidade, sendo evidente que a ré não pode apresentar resistência quanto a solução indicada pelos médicos que assistem a paciente/autora.

Os procedimentos solicitados pelo médico da demandante, de fato não estão previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mas não possuem conotação exclusivamente estética, pois é de conhecimento geral que a cirurgia bariátrica – de cobertura obrigatória nos planos de saúde – implica consequências anatômicas e morfológicas que também devem ser atendidas pelo plano.

Nesses casos, com a grande perda de peso, se faz necessária a cirurgia plástica para reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde, uma vez que não é suficiente a operadora do plano custear a cirurgia bariátrica, sendo fundamental o custeio também das cirurgias plásticas pós-bariátrica.

Logo, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual.

Destarte, vale lembrar, ainda, que, desde a edição da Lei 14.454/2022, está definitivamente encerrada a celeuma jurídica a respeito da taxatividade ou não do rol de procedimentos previstos pela ANS, conquanto que o art. 10, §12, da Lei de planos de saúde nº. 9.656/98, fora alterado para estabelecer que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, <u>CONSTITUI A REFERÊNCIA BÁSICA PARA OS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA</u>.

Dessa forma, convenci-me do acerto desse ensinamento, de sorte que não é outro o posicionamento adotado por este julgador, devendo ser julgado procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida em sede de Agravo de Instrumento.

Por fim, também não há o que se falar em coparticipação da parte autora em relação ao cumprimento da tutela (cirurgia realizada), já que consta dos autos extrato onde demonstra que existe um seguro do plano de saúde onde só pode ser cobrado no máximo por ano R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente as cirurgias, uma vez que o seguro deve cobrir o restante, devendo o plano de saúde acionar o seguro e se abster de cobrar valores pecuniários a maior.

DO DANO MORAL.

Com a negativa da cirurgia, viu-se a demandante privada de gozar da justa expectativa que possuía no concernente aos serviços contratados, que induz à configuração do dano imaterial invocado, hábil a ensejar compensação pecuniária.

O Superior Tribunal de Justiça já tem o posicionamento consolidado, no sentido de se afigurar cabível a caracterização de um prejuízo extrapatrimonial quando da constatação da ocorrência da negativa injusta da prestação do serviço pelo plano de saúde e em especial, quando inexiste dúvida jurídica razoável na interpretação do contrato, até porque, a matéria está lastreada em Súmula do TJPE e nos precedentes jurisprudenciais.

Destarte, utilizando-se dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando o caso concreto, deve o magistrado arbitrar os valores a título de dano moral, sem que, com isso, traga algum enriquecimento sem causa, mas que seja num patamar que represente o caráter reparatório e pedagógico dessa indenização, que se mostra prudente e em sintonia com a jurisprudência a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A presente fundamentação está em plena sintonia com o seguinte julgado do STJ:

> RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
>
> 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas pós-bariátrica (gastroplastia), consistentes na retirada de excesso de pele em algumas regiões do corpo humano (mamas, braços, coxas e abdômen), b) se ocorreu dano moral indenizável e c) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi exagerado.

3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM nº 1.766/2005 e Resolução CFM nº 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano.

4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017).

5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde.

6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.

Precedentes.

7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos

cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.

9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.

10. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais.

11. Na hipótese, de inexistir dúvida jurídica razoável na interpretação do contrato, a autora experimentou prejuízos com o adiamento das cirurgias plásticas reparadoras diante da negativa da operadora do plano de assistência médica, sobretudo porque agravou o estado de sua saúde mental, já debilitada pela baixa autoestima gerada pelas alterações anatômicas e morfológicas do corpo humano consequentes da cirurgia bariátrica, sendo de rigor o reconhecimento dos danos morais.
(...) 12. Recurso especial não provido. (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).

DO DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pleitos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) condenar a ré a dar cobertura ao tratamento de saúde da parte autora proposto pelo seu médico e descrito nesta peça de ingresso, necessários ao completo restabelecimento da parte autora, CONFIRMANDO-SE A TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

b) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido desde a data da sentença pela tabela ENCOGE e acrescido de juros moratórios legais de um por cento ao mês, estes contados a partir da citação válida, consoante preceitua o art. 405, do CCB e o entendimento pacificado na jurisprudência;

c) condenar, por fim, a parte demandada no ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10%, ambos calculados sobre o valor total da condenação atualizado pela tabela ENCOGE, com fulcro no que dispõe o artigo 85, caput e § 2º do código de processo civil.

De logo, determino que havendo apelação, a parte contrária deverá ser intimada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Decorrido o prazo do parágrafo anterior, com ou sem contrarrazões, proceda-se a IMEDIATA remessa dos autos ao TJPE.

INTIMEM-SE.

Transitado em julgado e cumpridas as citadas determinações, ARQUIVEM-SE.

Recife, data da assinatura digital.

Adriano Mariano de Oliveira

Juiz de Direito em Exercício Cumulativo

psrm

Assinado eletronicamente por: ADRIANO MARIANO DE OLIVEIRA
22/01/2024 20:22:11
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 158645384

24012220221119900000154962624

IMPRIMIR GERAR PDF